

1500807-64.2021.8.26.0630
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 28/07/2022
... (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Americana
Foro de Americana
2ª Vara Criminal
Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500807-64.2021.8.26.0630 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500807-64.2021.8.26.0630
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2277778/2021 - 04º D.P. AMERICANA, 20768824 - 04º D.P. AMERICANA, 1472/21/350 - 04º D.P. AMERICANA, 2277778 - 04º D.P. AMERICANA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MATHEUS DE OLIVEIRA DE SANTANA

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

MATHEUS DE OLIVEIRA DE SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput", c.c. artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal, porque, na data e local descritos na denúncia, tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel (cabos elétricos, um duto para cabos elétricos, dois disjuntores e uma tampa do aparelho de registro de consumo elétrico), avaliado em R\$130,00, e pertencente a W.P., não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A denúncia foi recebida em 20 de outubro de 2021 (fls. 83/85).
O réu foi citado (fls. 107), apresentando defesa prévia (fls. 128/132).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como o réu interrogado (fls. 142/143 e fls. 180).

O Doutor Promotor de Justiça (fls. 191/195), entendendo estarem suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu pelo delito de furto.

O Doutor Defensor requereu a absolvição por falta de prova ou atipicidade da conduta/crime impossível ou, alternativamente, a fixação de pena mínima (fls. 183/186 e 200).

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos autos de fls. 01/03, 09/11 e 12/18, e laudo de fls. 173/177.

A autoria é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho “é a certeza visual do crime”. A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:
“Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria” (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Na ocasião, o réu estava na posse do bem subtraído. A apreensão do bem subtraído em poder do acusado implica em forte prova indiciária, nos termos da melhor doutrina (cf. FRANÇOIS GORPHE, “De la Apreciación de las Pruebas”, tradução de Alcalá Zamora y Castillo, 1ª Ed., EJE, Buenos Aires, 1950, pág. 316; ERICH DÖRING, “La Prueba,

su Practica y Apreciación", tradução de Tomás Banzhaf, 1ª ed., EJE, Buenos Aires, 1986, pp. 367-8; CAMARGO ARANHA, "Da Prova no Processo Penal", 3ª Ed., Saraiva, 1994, cap. XVI, ns. 2 e 8, págs. 166 e 175).

Nesse caso, cabe à Defesa o ônus de provar a origem lícita do bem. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. (...)." (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6ªT. DJE 25.08.2014)

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor - validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. (...) (TJSP - APL: 00087038720118260533 SP 0008703-87.2011.8.26.0533, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 04/12/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2014)

"(...) é cediço que, em se tratando de delito patrimonial, a apreensão da "res" em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca para o fato, sob pena dessa presunção se transmutar em certeza apta a ensejar o decreto condenatório (...)" (TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº. 0078089-91.2010.8.26.0000, Rel. Des. Amado de Faria, j. 26.05.11);

PROVA - Furto - Apreensão da "res" em poder do agente - Presunção de responsabilidade - Entendimento: 31 (b) - Em sede de roubo, a apreensão da "res furtiva" em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que, se esta for inverossímil a presunção se transmudara em certeza autorizando o desate condenatório. RJDTACRIM VOLUME 18 ABRIL/JUNHO 1993 PÁGINA: 66 RELATOR:- PASSOS DE FREITAS

Ouvida em Juízo, a vítima Walter informou que a casa esta para alugar, e foi comunicado pela policia acerca da subtração do cabo de fiação. Narrou que foi até a casa e confirmou que foram retirados os bens. Por fim, tiveram outras subtrações no imóvel.

Não há nos autos prova de que a vítima/testemunha conhecia o réu anteriormente ou que tivesse intenção de prejudicá-lo, atribuindo-lhe falsamente a prática de crime.

No mesmo sentido foi o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência e terminaram por deter o réu.

O guarda municipal Alan informou que estavam em patrulhamento e foram solicitados ante um possível furto em andamento. Disse, ainda, que se dirigiram ao local, e localizaram o réu, com uma faca, cortando a fiação, sendo logo apreendido. Declarou, ainda, que no local encontraram uma chave e uma mochila, com pedaços pequenos de fiação. Por fim, foi solicitada a perícia.

Não procedem as alegações da defesa quanto à imprestabilidade dos depoimentos do policial. O depoimento dessas testemunhas tem o mesmo valor que o de qualquer

outra, ainda mais quando a mera alegação de sua imprestabilidade vem desacompanhada do menor indício de prova, como no caso dos autos. O entendimento jurisprudencial não é diverso:

APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. (...). 4. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10).(...). (TJSP; Apelação Criminal 3004956-73.2013.8.26.0318; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2017; Data de Registro: 17/11/2017)

O réu, ouvido em Juízo, negou a prática do furto. Declarou que foi abordado na calçada, por outros policiais. Disse que o portão estava aberto, e no local já existiam uma bolsa e pedaços de fios no chão. Reforça que não mexeu nos cabos de força.

No entanto, a versão pueril do réu em juízo, restou isolada no conjunto probatório.

Em que pese a possível ocorrência de diversas subtrações no local, os bens furtados, neste autos, encontram-se devidamente delimitados as fls. 12/13, com reconhecimento pela vítima (fls. 14/16), no mais, o policial ouvido foi claro ao afirmar que visualizou o réu puxando a fiação, além de apreender objetos para auxiliá-lo na empreitada criminosa (faca e chave de fenda – fls. 12).

Assim, não há que se falar, ainda, em crime impossível, pela ineficácia do meio, ante a existência de "monitoramento por vizinhos". Nos termos da jurisprudência: O crime impossível, também denominado tentativa inadequada, inidônea ou impossível, caracteriza-se pela impossibilidade de ocorrência da consumação, seja em razão da absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto, em observância da teoria objetiva temperada, adotada pelo art. 17 do Código Penal. Entrementes, dentro da sistemática da referida teoria, se os meios empregados ou o objeto do crime forem apenas relativamente inidôneos a produzir o resultado representado pelo agente, haveria tentativa, uma vez que o resultado somente não teria ocorrido por circunstância alheias à vontade do agente (CP, art. 14, II). 7. Adotando a teoria objetiva temperada, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial processado sob a forma do art. 543-C do Código de Processo Civil, consagrou a tese de que, embora os sistemas eletrônicos de vigilância e de segurança tenham por objetivo a evitação de furtos, sua eficiência apenas minimiza as perdas dos comerciantes, visto que não impedem, de modo

absoluto, a ocorrência de subtrações no interior de estabelecimentos comerciais. Nesse sentido, no mesmo julgamento, foi consolidado o entendimento de que somente se configura a hipótese de delito impossível quando, na dicção do art. 17 do Código Penal, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. 8. O caso concreto amolda-se perfeitamente à ratio decidendi dos precedentes invocados, porquanto o sistema de vigilância, de fato, apenas reduz a possibilidade de consumação dos furtos. Trata-se apenas de medida preventiva dos empresários na proteção de seus estabelecimentos, ante a ineficiência estatal, sendo completamente descabido cogitar conferir o benefício da excludente de tipicidade à criminalidade ocorrida contra aqueles que investem na segurança de seu patrimônio e, reflexamente, dos próprios clientes. 9. (...) (STJ, HC 351.194/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016) (Ap. nº 0079169-61.2015.8.26.0050, 12ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. MARCELO GORDO, 12.09.2018)

Também não prospera a alegação de crime impossível sob o argumento que a ação teria sido vigiada desde o início pelas seguranças. O fato de a apelante ter sido monitorada por câmeras de segurança não conduz à conclusão de que era impossível a consumação do crime. Com efeito, a Súmula 567 do C. Superior Tribunal de Justiça, assim dispõe: "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. (Ap. nº 0008099-53.2016.8.26.0048, 15ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Cláudio Marques, 20.09.2018).

Desta forma, os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra o acusado.

Assim, em que pese a defesa apresentada, não é possível o reconhecimento da desclassificação do delito, ou a absolvição.

Por fim, o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, qual seja, o de ter sido surpreendido pelos policiais no local.

Diante da robustez do conjunto probatório, a condenação do acusado pela prática de furto é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

O réu possui condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que uma delas (fls. 39/46) deve ser considerada na dosimetria da pena para a fixação da pena-base, como mau antecedente. A prática reiterada de crimes, por ele, indica a má formação da personalidade, sempre voltada à prática de ilícitos criminais, antecedentes que impõem majoração da pena base como circunstância judicial. Exaspero, por isso, a pena base em 1/6 (um sexto), considerado o mínimo, delimitando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, anoto que o réu é também reincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 39/46. Acrescento à pena base, portanto, mais 1/6 (um sexto), pela reincidência, perfazendo um total de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão e doze dias-multa.

O entendimento da doutrina é pela possibilidade de utilização de condenações distintas para avaliar maus antecedentes e para a agravante da reincidência: "Cumprir precisar que na hipótese de diversas condenações definitivas, uma valerá para majorar a pena-base, como maus antecedentes, e a outra para respaldar o aumento da reincidência, sem qualquer ofensa ao princípio do non bis in idem." (Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", ed. Oliveira Mendes - APAMAGIS - Associação Paulista de Magistrados, 1997, p.3).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

STJ, SÚMULA N. 241 - A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais. 3. (...). 5. Habeas corpus concedido de ofício para redimensionar a pena, nos termos do voto. (HC 528.390/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020)

Tendo em vista que o delito se deu na forma tentada, diminuo a pena da 1/2 (metade), tendo em vista o iter criminis percorrido, perfazendo assim um total de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

Não é possível o reconhecimento do privilégio constante do § 2º, do artigo 155, do Código Penal, para que o benefício fosse concedido, é requisito que o réu seja primário e portador de bons antecedentes. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA. EXPRESSIVO VALOR DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a aplicação da figura do furto privilegiado é necessário que o agente seja primário e de pequeno valor a coisa subtraída.

2. No caso, um dos réus é reincidente e o valor da coisa subtraída, somado ao prejuízo suportado pela vítima para o conserto de sua residência em razão do arrombamento, não pode ser considerado pequeno para fins de reconhecimento do privilégio pleiteado. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1511869/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)

Ademais, os péssimos antecedentes do réu desaconselham a adoção de tal benefício.

À míngua de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, em razão da reincidência do réu.

O réu poderá apelar em liberdade, tendo em vista que responde solto ao presente processo.

O réu, por ser reincidente, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Apelação criminal. Furto. Reincidência. Furto privilegiado. Pena privativa de liberdade. Substituição. Penas restritivas de direitos. A reincidência específica faz inviável falar-se em furto privilegiado ou em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. (TJSP; Apelação Criminal 1500146-79.2018.8.26.0569; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal condenar o réu MATHEUS DE OLIVEIRA DE

SANTANA à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 06 (seis) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 155, "caput", c.c. artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Por fim, considerando ser o réu assistido pela defensoria pública, presumindo-se a insuficiência de recursos, isento-o das custas.

P. I. C.

Americana, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA